Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Naviraí

1.ª Vara Cível

Conclusão

Aos 16/07/2018 04:22:43 foram estes autos conclusos ao Dr. Eduardo Magrinelli Júnior, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Naviraí-MS.

SENTENÇA

Vistos e examinados estes autos sob nº 0803610-50.2017.8.12.0029 de **AÇÃO Procedimento Comum** em que é **Autora:** Hillary Vitória Pinheiro Andrade e **Réu:** Município de Naviraí e outro

Hillary Vitória Pinheiro Andrade, qualificada e representada nos autos por seu genitor, ingressou com a presente *Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Satisfativa* em face do **Município de Naviraí** e do **Estado do Mato Grosso do Sul**, ambos qualificados nos autos, alegando, em síntese, que possui seis anos de idade e que foi diagnosticada pelo pneumologista com urticária alérgica. Assevera que por conta de tal enfermidade necessita utilizar vacinas dessenbilizantes imunoalérgicas – fases 1, 2, 3, 4 manutenção – árcaros e fundos, as quais o seu genitor não possui condições de adquirir. Conta que tentado obter administrativamente o tratamento indicado dos Requeridos, não obteve êxito. Objetiva com a presente demanda, a condenação dos Requeridos ao fornecimento de vacinas Dessensibilizantes Imunoalérgicas, fases 1,2,3,4 e manutenção, 04 (quatro) frascos para cada fase, num total de 08 (oito) frascos. Fez outros pedidos. Instruiu a inicial com os documentos de fls. 16/25.

Antecipação dos efeitos da tutela deferida às fls. 33/37 mediante prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico – NAT.

Citados, os Requeridos ofereceram contestações às fls. 43/49 e às fls. 61/76.

O Requerido Estado de Mato Grosso do Sul em sua defesa, arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito alegou, em suma, que deve ser dada interpretação correta ao artigo 198, inciso II, da Constituição Federal e aos arts. 19-M e 19-N da Lei n. 8.080/90, bem como defendeu a inconstitucionalidade da pena de sequestro de valores e fixação de multa diária e, por fim, aduziu ser ilegal o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Já o Requerido Município de Naviraí na contestação apresentada, alegou, em suma, que medicamento pleiteado pela Requerente não faz parte do RENAME, assim obrigá-lo a fornecimento o medicamento que não faz parte da lista, deixará de atender de atender demais cidadãos, uma vez que não existe receita para suporta o custo. Assevera que o acolhimento pretensão do autor implicaria violação aos princípios da isonomia, reserva do possível e separação dos poderes, configurando, em suma, indevida ingerência da atividade administrativa. Juntou documentos.

Mod. 790251 - Endereço: Rua Higino Gomes Duarte, 155 (Edifício do Fórum), Fax: (067) 3461-2644
Centro - CEP 79950-000, Fone: (67) 3461-1657, Naviraí-MS - E-mail: nav-1vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 31/08/2018 às 14:13 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803610-50.2017.8.12.0029 e código UZoOnBhg.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Naviraí

1.ª Vara Cível

Às fls. 92/109 foi juntada decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1401490-38.2018.8.12.0000.

Réplica apresentada pela parte Autora às fls. 110/132, oportunidade em que especificou as provas para produção.

Em seguida, os Requeridos informaram que não possuem provas a serem produzidas (fls. 137 e fls. 142/144).

É o relatório no essencial.

Decido.

Inicialmente cumpre salientar que o REsp n. 1.657.156/RJ/STJ já foi julgado, possibilitando, assim, o julgamento da presente demanda.

No tocante à preliminar de **ilegitimidade passiva,** é matéria já consolidada na jurisprudência, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo dúvida de que as três esferas da administração detêm, solidariamente, legitimidade para responder pelas demandas atinentes à saúde, pouco importando o estabelecimento de critérios de divisão de suas competências no âmbito administrativo. Nesse sentido, são os seguintes julgados:

> *"(...) O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, estados-membros e municípios, de modo que qualquer destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros.*
> *Precedentes do STJ. (...) [AgRg no REsp 1225222/RR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 05/12/2013]*
>
> *"(...) A CF/1988 erige a saúde como um direito de todos e dever do Estado (art. 196). Daí, a seguinte conclusão: é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária para a cura de suas mazelas, em especial, as mais graves. Sendo o SUS composto pela União, Estados e Municípios, impõe-se a solidariedade dos três entes federativos no pólo passivo da demanda.(...)" [AgRg no REsp 690.483/SC, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2005, DJ 06/06/2005, p. 208]*

Aliás, o tema já está resolvido inclusive perante o Supremo Tribunal Federal:

> *AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.* ***OBRIGAÇÃO SOLÍDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO*** *EM MATÉRIA DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO. I − O Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN,* ***fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação***

Mod. 790251 - Endereço: Rua Higino Gomes Duarte, 155 (Edifício do Fórum), Fax: (067) 3461-2644, Centro - CEP 79950-000, Fone: (67) 3461-1657, Naviraí-MS - E-mail: nav-1vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 31/08/2018 às 14:13 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803610-50.2017.8.12.0029 e código UZoOnBhg.

> ***no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária***. *II − Ao contrário do alegado pelo impugnante, a matéria da solidariedade não será discutida no RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio. III - Agravo regimental improvido (AI 808059 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010, DJe-020 DIVULG 31-01-2011 PUBLIC 01-02-2011 EMENT VOL-02454-13 PP-03289)* - original sem grifos

Dessarte, ante o firme entendimento jurisprudencial sobre a matéria, totalmente despiciendas maiores ilações, devendo ser afastada, sem outras delongas, a preliminar arguida.

No mais, conheço diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I, do Novo Código de Processo Civil, pois desnecessária a produção de outras provas.

O ordenamento jurídico brasileiro tutela o direito à saúde, determinando o artigo 196 da Constituição Federal que:

> "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Por sua vez, a Lei n.º 8.080, de 19/9/90, que trata das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, estatui em seu artigo 2.º que "A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício." E, no artigo 7.º, que "As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde − SUS, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: I − universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; II − integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; IX − descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo: a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;".

Basta o dispositivo previsto no texto constitucional citado para se chegar à conclusão de que se deve garantir o direito de todos, <u>independentemente da condição financeira,</u> à saúde. As normas infraconstitucionais, que procuram dar efeito integrador ao texto constitucional, seriam até despiciendas se existisse a consciência, por parte de todos os responsáveis pelas administrações dos entes federados, de que a Constituição Federal não é puramente analítica. A Constituição, com sua força normativa, constitui energia que deve influir na realidade. O dever da Administração de adquirir o necessário ao atendimento de pessoas doentes, imposto pela Constituição, não pode ser inviabilizado enventualmente através de entraves burocráticos e questiúnculas referentes à competência deste ou daquele órgão para distribuição. A distribuição de competências entre os entes federados é firmada para melhor servir aos cidadãos e não para aumentar seus sofrimentos e

Mod. 790251 - Endereço: Rua Higino Gomes Duarte, 155 (Edifício do Fórum), Fax: (067) 3461-2644, Centro - CEP 79950-000, Fone: (67) 3461-1657, Naviraí-MS - E-mail: nav-1vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 31/08/2018 às 14:13 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803610-50.2017.8.12.0029 e código UZoOnBhg.

angústias, motivo pelo qual há solidariedade entre eles.

A edição da Lei nº 12.401/2011, em que pese sua importância e necessidade de respeito, não pode implicar em preterimento dos direitos do cidadão. A lei deve respeito à Constituição Federal e o Poder Judiciário é o garante das promessas do constituinte. Assim, como a Carta Magna traz a promessa de ampla proteção no campo da saúde, não pode o ente público se esquivar da sua obrigação, até porque estamos diante de tema que perpassa pela dignidade da pessoa humana. O Tribunal de Justiça do Estado, a respeito do tema já decidiu:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 12.401/2011 – PREVISÃO CONSTITUCIONAL QUE PREVALECE SOBRE LEI, PORTARIA OU ATO NORMATIVO INFERIOR – DIREITO À SAÚDE – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR – PERIGO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – MEDICAMENTO EXPERIMENTAL – SEM RELEVÂNCIA DESDE QUE INDICADO POR MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE – RECURSO IMPROVIDO. Não há que se falar no reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei n. 12.401/2011, posto que já é pacífico o entendimento de que a garantia ao acesso igualitário das pessoas saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal está acima de qualquer lei, portaria ou ato normativo inferior. Uma vez sopesados os interesses de ambas as partes, verifica-se que o princípio da integralidade que é fundamento do interesse do recorrente, não deve prevalecer sobre o princípio basilar da pretensão do recorrido, que é o da dignidade da pessoa humana. Diante da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, como a prova inequívoca do direito e a verossimilhança das alegações acerca da necessidade do medicamento pleiteado, a decisão a quo deve ser mantida. Já é sedimentado o entendimento de que, se beneficiar o paciente, o médico pode utilizar um medicamento para finalidades diversas das indicadas, mesmo que em fase experimental. (TJMS, Quarta Câmara Cível, relator Desembargador Claudionor Miguel Abss Duarte, agravo nº 2012.015841-8, julgado em 17.07.2012).*

É inequívoca a responsabilidade do réu em fornecer assistência à saúde a quem dela necessitar, o que inclui o oferecimento de medicamentos, exames, consultas, procedimentos cirúrgicos etc.

In casu, a Requerente objetiva a concessão de vacinas dessensibilizantes em razão de ser portadora de urticaria alérgica recorrente, consoante laudo médico de fls. 23, cuja medicação não é normalmente fornecida pela Rede Pública de Saúde.

Com efeito, mesmo considerando o julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, no qual restou decidido que para o fornecimento de medicamentos alternativos deverá ser primeiramente comprovada a ineficácia dos medicamentos dispensados pelo SUS, no presente caso, a vacina pretendida foi prescrita por profissional habilitado e credenciado ao SUS , o qual afirmou a impossibilidade de substituição da medicação, sendo que o não tratamento implica em piora na qualidade de vida do menor, havendo, inclusive, o risco da enfermidade evoluir para um mal maior e, consequentemente, prejudicar o pleno desenvolvimento do Requerente.

Mod. 790251 - Endereço: Rua Higino Gomes Duarte, 155 (Edifício do Fórum), Fax: (067) 3461-2644, Centro - CEP 79950-000, Fone: (67) 3461-1657, Naviraí-MS - E-mail: nav-1vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 31/08/2018 às 14:13 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803610-50.2017.8.12.0029 e código UZoOnBhg.

Portanto, demonstrado que a vacina pleiteada na inicial é imprescritível para o Requerente, deve ser acolhido o pedido inicial.

Em casos semelhantes já decidiu o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul:

> *REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196, DA CF – SUBSTITUIÇÃO DE MEDICAMENTO POR OUTRO FORNECIDO PELO SUS – IMPOSSIBILIDADE – FÁRMACO PLEITEADO QUE TAMBÉM É DISPENSADO PELA REDE PÚBLICA – HONORÁRIOS – ARTIGO 20, §§ 3º E 4º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.*
> *O artigo 196, da Constituição Federal prescreve que é dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário das pessoas à saúde, estando este dever constitucional acima de qualquer lei, portaria ou qualquer outro ato normativo, porquanto o que se visa garantir é o direito primordial à vida. Não é dado ao Estado (União, Estados e Municípios) opor resistência ao fornecimento do tratamento presumidamente mais eficaz no tratamento da doença, simplesmente porque a enfermidade apresentada pelo doente difere daquelas indicadas em Protocolos Clínicos. Deve ser mantida a verba honorária arbitrada em primeira instância se restaram atendidos os critérios descritos no artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC. (Relator(a): Des. Eduardo Machado Rocha; Comarca: Sidrolândia; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Data do julgamento: 27/10/2015; Data de registro: 27/10/2015).*

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (Relator(a): Juiz Jairo Roberto de Quadros; Comarca: Mundo Novo; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Data do julgamento: 26/05/2015; Data de registro: 26/05/2015).*

Não se trata de judicializar políticas públicas, mas de garantir o atendimento adequado a quem dele necessita. É fazer com que o Estado (sentido amplo) cumpra seu papel, cumpra as políticas públicas com as quais deveria estar comprometido, cumpra os fins do Estado estabelecidos na Constituição.

No que toca à imposição de multa, é ela perfeitamente possível, conforme reiteradamente os tribunais superiores têm decidido, não tendo a Fazenda Pública prerrogativa de não se sujeitar a referida técnica executiva.

Quanto ao pagamento das custas processuais, que não se confundem com a multa, como cediço, os entes públicos são isentos de seu pagamento.

Em relação aos honorários advocatícios, tem-se que no presente caso é incabível condenar o Estado ao pagamento de tal verba em favor da

Mod. 790251 - Endereço: Rua Higino Gomes Duarte, 155 (Edifício do Fórum), Fax: (067) 3461-2644, Centro - CEP 79950-000, Fone: (67) 3461-1657, Naviraí-MS - E-mail: nav-1vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 31/08/2018 às 14:13 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803610-50.2017.8.12.0029 e código UZoOnBhg.

Defensoria Pública, nos termos da Súmula 421 do STJ, que assim dispõe:

> *"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".*

Dessa maneira, ocorreria confusão se houvesse condenação do Estado de Mato Grosso do Sul a pagar honorários à Defensoria Pública que é por si mantida.

Ante o exposto, confirmando neste momento a antecipação dos efeitos da tutela, **JULGO PROCEDENTE** o pedido que o **Hillary Vitória Pinheiro Andrade** fez em desfavor do **Município de Naviraí e Estado de Mato Grosso do Sul**, qualificados, para o fim de determinar aos réus que forneça, por meio de seu órgão executor competente, à Requerente as **vacinas dessensibilizantes,** durante todo o tratamento, na quantidade que for solicitada para tanto pelo médico que o(a) acompanha, mediante receituário, no prazo de 15 dias após a solicitação, sob pena de fixação ulterior de multa, caso descumprida esta ordem.

Sem custas, *ex vi legis*.

Condeno tão somente o réu Município de Naviraí ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, que fixo em R$500,00(quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §8º do Código de Processo Civil, já considerado o grau de zelo do profissional, a importância e a natureza da causa, o tempo e o lugar da prestação do serviço.

Declaro **extinto** o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Sentença sujeita a reexame, pois não é certo o valor da condenação, nos termos do art. 496, § 3º, do CPC e Súmula 490 do STJ.

Assim, decorrido o prazo recursal, mesmo sem oposição de recurso pelas partes, remetam-se os autos ao E. TJMS para reexame.

Havendo o trânsito em julgado, arquive-se com as formalidades.

P.R.I.C.

Naviraí, **datado e assinado digitalmente.**

Eduardo Magrinelli Júnior
Juiz de Direito

Mod. 790251 - Endereço: Rua Higino Gomes Duarte, 155 (Edifício do Fórum), Fax: (067) 3461-2644, Centro - CEP 79950-000, Fone: (67) 3461-1657, Naviraí-MS - E-mail: nav-1vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDUARDO MAGRINELLI JUNIOR, liberado nos autos em 31/08/2018 às 14:13 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803610-50.2017.8.12.0029 e código UZoOnBhg.